

1500281-23.2020.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... se deparara com diversas ocorrências de tráfico e, por isso, observavam com atenção quem ficava por ali. Alegou que a ré ficou nervosa ao vê-los, o que despertou a suspeita e motivou a abordagem, tendo ela prontamente confessado o tráfico, dizendo que estaria vendendo desde as 14h00min. daquele dia. Relatou que ré tinha 5 porções de cocaína consigo e teria afirmado que havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500281-23.2020.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500281-23.2020.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2101923/2020 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 11106574 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 899/20/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2101923 - DEL.POL.SALTO, 899/20/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

NATHALIA LOPES FLORIANO

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa.

Vistos.

NATHALIA LOPES FLORIANO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j" (calamidade pública) do Código Penal, porque, em 25 de abril de 2020, por volta de 18h12min, na Rua Campinas, altura do nº 725, Jardim Cidade, nesta cidade e comarca de Salto, durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 12 (doze) porções de "cocaína", com massa bruta de 29,7g (vinte e nove gramas e setenta centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi ofertada em 14 de maio de 2020 (fls. 87/89), a ré foi notificada (fls. 109) e apresentou defesa prévia (fls. 113). A denúncia foi recebida em 15 de

março de 2022 (fls. 116/118) e a ré foi citada (fls. 144-145).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum (fls. 151 e 164) e, ao final, a ré foi interrogada (fls. 165).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação da acusada nos termos da denúncia, com fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da agravante constante da inicial e da atenuante atinente à menoridade relativa da ré, incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com substituição por restritivas de direitos (fls. 173/179). A Defesa, por sua vez, suscitou a presença de nulidades e, no mérito, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição da acusada por insuficiência probatória. Subsidiariamente, secundou os pedidos da acusação (fls. 181/189).

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, necessário pontuar a inexistência das nulidades processuais apontadas, em memoriais, pela Defesa.

Não há que se falar em inépcia da inicial, já que a denúncia foi perfeitamente capaz de possibilitar a defesa plena do réu, que foi capaz de rebater os argumentos da acusação em todas as fases da instrução penal.

Ainda assim, caso houvesse constatado alguma nulidade que o impossibilitasse de realizar a plena defesa do acusado, o defensor certamente a teria alegado desde o início, o que não ocorreu e também não o impossibilitou de defender a ré de forma plena, como dito, em todo o decorrer da instrução.

Em suma, a peça inicial foi suficiente para a garantia do direito constitucional de ampla defesa, não tendo havido qualquer prejuízo ao acusado.

Assim, afasto a preliminar de inépcia da inicial.

Da mesma maneira, a decisão que recebeu a denúncia cumpriu todos os requisitos legais, tendo sido suficientemente fundamentada. Tanto que proporcionou à acusada a condição de se defender amplamente dos fatos narrados, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório ou cerceamento à sua ampla defesa, restando plenamente garantidos os direitos constitucionalmente garantidos à acusada.

O acima pontuado se confirma, ainda, porque as alegações sobre a suposta falha são genéricas, não se tendo demonstrado qualquer prejuízo realmente sofrido pela acusada, até porque, como dito, foram observados todos preceitos constitucionais.

Ademais, o nobre causídico, poderia e deveria ter suscitado eventual nulidade a qualquer tempo, caso entendesse que a acusada poderia vir a ser prejudicada, levantando pontos que necessitassem de observação. Entretanto, optou por não mais se manifestar nos autos até a apresentação dos memoriais.

Finalmente, antes de adentrar ao mérito, cumpre salientar que não é o caso de nulidade da audiência de instrução, como bem desejaria a Defesa, porquanto ao juízo, na busca da verdade real, cabe fazer questionamento sobre pontos que entenda cruciais à solução da demanda. Ademais, além das alegações genéricas da Defesa, não se provou qualquer prejuízo à acusada em razão da dinâmica da audiência de instrução, nem que se tenha ferido o contraditório ou a ampla defesa, nem muito menos que se tenha tolhido às partes, seu direito de efetuar perguntas e esclarecer pontos que reputassem obscuros.

Superadas tais questões, passo a julgar o mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/03), autos de exibição/apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 04/05), e laudo de exame químico toxicológico (fls. 147/149), além dos demais elementos informativos e da prova oral, colhida durante as duas fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre a acusada.

A ré, em sede policial, confessou o tráfico e disse que o dinheiro com ela encontrado era proveniente da venda de drogas (fls. 09/10). Em juízo, tornou a confessar os fatos. Disse que traficava desde às 14h00min daquele dia e havia terminado seu "turno", em que havia vendido 01 kit com 10 porções, pelo que havia

recebido R\$50,00. Alegou que possuía dívida alta no bar de garotas onde trabalhava e estava vendendo drogas para pagar essa dívida e sair desse local. Disse que as porções que trazia consigo no momento da abordagem seriam para consumo próprio, mas afirmou que parou de usar drogas, depois disso, casou-se, trabalha, e nunca teve outra ocorrência, antes ou depois, dos fatos aqui narrados (fls. 165).

Antônio Brasileiro Magalhães Filho, guarda municipal, disse que estavam patrulhando o local, onde já se deparara com diversas ocorrências de tráfico e, por isso, observavam com atenção quem ficava por ali. Alegou que a ré ficou nervosa ao vê-los, o que despertou a suspeita e motivou a abordagem, tendo ela prontamente confessado o tráfico, dizendo que estaria vendendo desde as 14h00min. daquele dia. Relatou que ré tinha 5 porções de cocaína consigo e teria afirmado que havia vendido um kit com 14 porções e já tinha entregue o dinheiro a uma pessoa encarregada de coletar o valor, tinha R\$27,00 em dinheiro, sendo apenas R\$20,00 oriundos da droga. Contou que a ré mostrou-lhes um local onde haveria mais 7 papelotes espalhados ao solo, pela via, em pontos diferentes. Relatou que a ré teria dito que estava vendendo para pagar dívidas que havia contraído (fls. 151). Ubiraci Jose Nantes Gimenez, guarda municipal, prestou depoimento em perfeita consonância com o de seu colega de farda, esclarecendo que o nervosismo da ré foi notado porque, assim que os viu, ela passou a sentar-se e levantar-se, repetidamente, sem saber para onde ir. Disse, também, que depois dos fatos, ela não foi mais vista no local (fls. 164).

Encerrada a instrução, restou comprovada a ocorrência dos fatos narrados na inicial acusatória.

A ré, ainda que por via transversa, confessou os fatos, malgrado tenha buscado alterar pontos da ocorrência, na tentativa de eximir-se de culpa.

Já a versão dos guardas municipais coaduna-se com o restante do conjunto probatório.

Nesse trilhar, os depoimentos dos mencionados agentes foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por

dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexistiu qualquer indício de que pretendiam, deliberadamente, prejudicar a acusada que sequer conheciam. Observo que um dos agentes foi incisivo ao informar, inclusive, que depois dessa ocorrência, não voltou a ver a ré em pontos de tráfico da cidade, o que reforça o argumento de que a intenção dos guardas, ao prestarem seus depoimentos, é a de esclarecerem os fatos como ocorridos.

Acrescento que não se fez prova alguma de que as porções de cocaína encontradas em poder da acusada fossem diferentes daquelas encontradas ao solo pelos guardas municipais, após indicação feita por Nathalia.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do tráfico, na forma mencionada na inicial.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173)

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546)

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

Por fim, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 25 de abril de 2020, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à saciedade que a ré praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incursa no artigo 33, caput, da Lei

Federal nº 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em 25 de abril de 2020, por volta de 18h12min, na Rua Campinas, altura do nº 725, Jardim Cidade, nesta cidade e comarca de Salto, durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para venda e entrega a consumo a terceiros, ainda que gratuitamente, 12 (doze) porções de "cocaína", com massa bruta de 29,7g (vinte e nove gramas e setenta centigramas), todas acondicionadas em invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, restaram provadas, de forma inconteste, a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta da acusada, razão pela qual, passo a lhe aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, à primariedade da ré e ao fato de que a quantidade e a natureza da droga apreendida em poder da acusada não fogem do que usualmente é apreendido em feitos dessa natureza na comarca, fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa para o delito de tráfico (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006).

Como anteriormente mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, já que o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, razão pela qual aumento sua pena, para o crime de tráfico, para de 05 anos e 06 meses de reclusão e 550 dias-multa.

Incide a atenuante da menoridade relativa, pois a acusada, nascida em 25 de janeiro de 2000, era menor de 21 anos à época do crime. Ainda que tenha buscado alterar alguns pontos em seu depoimento, entendo que a confissão da ré, aos guardas municipais, à autoridade policial e, também, em juízo, mostram-se suficientes para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Assim, ante a presença de uma agravante e de duas atenuantes, a pena deve retornar ao patamar mínimo inicialmente fixado, não sendo possível reduzir a pena aquém do mínimo legal nesta fase, em respeito à Súmula 231 do Colendo STF.

Inexistem causas de aumento e, no tocante à redução prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, em 18.08.2022, por ocasião do julgamento do mérito nos Recursos Especiais nº 1.977.027/PR e nº 1.977.180/PR, processos paradigma do Tema nº 1139 - Tráfico - Privilegiado - Inquéritos - Ações - Penais - Andamento, fixou a seguinte tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06." .

Assim, a primariedade da ré se mostra como circunstância preponderante que permite, no presente caso, a aplicação do § 4º. do art. 33, da lei em tela, razão pela qual reduzo a pena da acusada de dois terços (2/3), resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Torno a pena definitiva à míngua de outras causas modificadoras, e fixo a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação e CONDENO a ré NATHALIA LOPES FLORIANO, qualificada nos autos, RG 71.897.302 (fls. 99), como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 166 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, considerando a pena fixada, os elementos mencionados para a concessão da benesse do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e o fato de o crime não ter sido cometido com violência, mostra-se perfeitamente possível a conversão prevista no artigo 44, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º., alínea "c", do mencionado estatuto. Assim, nos termos do parágrafo 2º do referido artigo, converto a pena privativa de liberdade aplicada ao réu em duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1) prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época do efetivo pagamento, à entidade pública ou privada com destinação social (a ser designada oportunamente pelo juízo da execução), que deverá ser revertido na compra e respectiva entrega de alimentos ou produtos não perecíveis; 2) prestação de serviços à comunidade, que, nos termos do artigo 46, par. 30., do referido Codex, será convertida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho e devendo ser cumprida em entidades especializadas (par. 20., do mesmo artigo). Outrossim, caso descumpra injustificadamente a substituição concedida, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o aberto.

Tendo em vista que a acusada permaneceu solta por quase toda a instrução do feito, não tendo infringido as regras do benefício que lhe fora concedido nos autos de Habeas Corpus de nº 2078415-65.2020, que não causou embaraços ao deslinde do feito e que compareceu aos atos para os quais fora intimada, concedo-lhe o direito de aguardar o julgamento definitivo do feito antes de continuar o cumprimento da pena nos moldes ora fixados.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos nestes autos em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/06). Outrossim, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Considerando não haver notícias sobre o julgamento definitivo dos autos de Habeas Corpus de nº 2078415-65.2020, informe-se o julgamento do presente feito à Egrégia 14ª Câmara de direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Arbitro os honorários advocatícios do Procurador nomeado, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá ao advogado interessado providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 17 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA